

1500969-76.2020.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... que se destinavam, sim, ao tráfico, valendo anotar. Ou seja, as circunstâncias do fato, aliados às máximas de experiências, indicam de forma concludente que a droga era destinada, sim, a ulterior entrega ao consumo de terceiros, e ainda que o acusado fosse usuário, tal por si só não elide o tráfico, pois é bastante corriqueiro nos dias atuais a prática do tráfico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500969-76.2020.8.26.0571 - Controle 2020/001281

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REINALDO SANTOS ALAPONE

Data da Audiência:

17/03/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e do Acusado Reinaldo Santos Alapone. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foi ouvida a testemunha William de Medeiros dos Santos arrolada pelas partes. A Acusação e a Defesa desistiram da oitiva da testemunha Júlio Aparecido Paes, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, acha-se processado o acusado como incurso no artigo 33 da Lei de Tóxicos, em face dos fatos detalhadamente narrados na denúncia. Concluída a instrução, a ação penal merece proceder. A materialidade delitiva encontra respaldo no laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos. Autoria e existência delitiva, ao seu turno, vêm comprovadas nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Ouvidos nos autos, tanto em juízo como em solo judicial, os policiais militares narraram toda dinâmica das diligências, desde o momento em que receberam informação de um cidadão sobre o tráfico de drogas praticado pelo acusado no local, até a efetiva abordagem e encontro em seu poder de cinco porções de crack, embaladas e prontas para o comércio espúrio, além de R\$ 60,00 em dinheiro. Diante disso, seguindo o que o informante havia mencionado, vasculharam o matagal adjacente, onde o acusado,

segundo noticiado, tomava a droga para repassar aos eventuais adquirentes, e ali puderam localizar dezesseis porções da mesma droga, além de cocaína, pelo que foi preso em situação de flagrante. As palavras dos policiais revestem-se de imensurável valor probatório, uma vez que isentas e desprovidas de qualquer intenção de prejudicar o agente. Demais disso, não há nenhum elemento capaz de indicar uma suposta suspeição do agente público; ao contrário, revela de forma absolutamente convincente toda dinâmica da diligência que resultou na prisão em flagrante. Dessa forma, patente a conduta atribuída ao réu, sendo certo que a quantidade da droga, dividida em porções e acondicionada em unidades embaladas e prontas para a mercancia clandestina, indica claramente que se destinavam, sim, ao tráfico, valendo anotar. Ou seja, as circunstâncias do fato, aliados às máximas de experiências, indicam de forma concludente que a droga era destinada, sim, a ulterior entrega ao consumo de terceiros, e ainda que o acusado fosse usuário, tal por si só não elide o tráfico, pois é bastante corriqueiro nos dias atuais a prática do tráfico para sustento do próprio vício. Portanto, demonstradas autoria e materialidade, pugna a Justiça Pública pela procedência da ação penal, condenando-se o acusado nos termos da denúncia, devendo, na mesma toada, ser fixado regime inicial fechado para o débito da sanção carcerária. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz. O acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 do Código Penal. Ocorre que a pretensão persecutória não merece prosperar, visto que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao acusado. Senão vejamos. I-- DA NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR FALTA DE PROVAS. As provas produzidas não atestam a prática delitiva por parte do réu. O policial William narrou que apreenderam em poder do réu 5 porções de crack e dinheiro. Informou que os demais entorpecentes foram encontrados em um terreno. No momento da abordagem, o réu negou a propriedade das drogas, afirmando ser mero usuário. O acusado, interrogado sob o crivo do contraditório, negou a propriedade dos entorpecentes. Vê-se que o réu não foi visto em contato com pessoas, que não foi preso com grande quantidade de entorpecentes e nem com apetrechos ou instrumentos que indicassem a prática delitiva. Eventual denúncia, sem qualquer identificação do denunciante, não se mostra suficiente para prolação de sentença condenatória. Ainda, é de se destacar que não há como imputar ao réu a propriedade entorpecentes encontradas em terreno, local aberto e de acesso livre por qualquer pessoa. Assim, havendo dúvidas acerca da prática delitiva, o que atrai a incidência do princípio in dubio pro reo, deve o acusado ser absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP. II- DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11343/06: A acusação se baseia, tão somente, em apreensão de diminuta quantidade entorpecentes e como o réu não foi preso mantendo contato com pessoas, mas apenas - de acordo com os depoimentos - na posse de pequena quantidade de entorpecente, conduta mencionada melhor se adequa àquela prevista no art. 28 da lei de drogas. Aliás, o próprio réu esclareceu que se trata de usuário. A distinção do tipo legal do artigo 28 da Lei n. 11.343 do tipo penal do art. 33 da mesma lei se dá por força do elemento subjetivo específico "para consumo pessoal". Conquanto o tipo do art. 28 contenha mais elementos subjetivos, não cabe à Defesa provar esse fim específico, mas sim cabe ao acusador demonstrar que esse fim não existia; e isto por força do princípio da presunção de inocência e da fórmula do in dubio pro reo, que determinam que se presume que o acusado incorreu no tipo penal menos grave enquanto o conjunto probatório não indicar seguramente no sentido contrário. Ainda, o fato de as substâncias estarem embaladas individualmente nada indica: se alguém vende a droga fracionada, alguém a compra também fracionada, de modo não há como inferir a mercancia apenas em razão desta circunstância. Destaque-se, por fim, que o réu declarou que possuía os entorpecentes para seu consumo pessoal. De fato, o caso envolve diminuta quantidade de entorpecente, indicando se tratar de hipótese de uso. Desta maneira, diante da ausência de evidências de que o réu visasse comercializar e obter lucro (circunstância inerente ao tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06) deve prevalecer o entendimento de que a classificação jurídica correta para a conduta atribuída a ele é a do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, devendo-se operar, portanto, a desclassificação, com suas consequências legais. III- DA

APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. Requisitos legais preenchidos. Na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado é primário e tem bons antecedentes. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu, à vista da primariedade do denunciado. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida”. (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

IV- TESES SUBSIDIÁRIAS – Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer: i) fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, considerando que a culpabilidade do acusado não extrapola aquela inerente ao respectivo tipo penal; (ii) seja fixado o regime aberto de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, do CP, bem como considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e da súmula nº 440 do E. STJ; (iii) seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento, a manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP) – art. 387, § 1º, do CPP, requerendo, subsidiariamente, a substituição da prisão por uma das cautelares arroladas no art. 319 do CPP. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. REINALDO SANTOS ALAPONE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque, no dia 05 de julho de 2020, por volta das 16 h e 37 min, na Rua Pilar do Sul, n. 331, Vila Paulo Ayres, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo, guardava, mantinha em depósito e ocultava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e uma porções de “crack”, com peso de 4,27 gramas, e seis porções de “cocaína”, com peso de 4,03 gramas. Em 05 de agosto de 2021 foi acolhido o pedido para decretação da prisão preventiva, fls. 108/109. Notificado por edital fls. 116, em seguida foi dado cumprimento ao mandado de prisão, fls. 122, a Defensoria Pública requereu a liberdade provisória, fls. 117/118, o MP manifestou-se, fls. 144, o pedido não foi analisado, aguardou-se a notificação pessoal e a apresentação de defesa, fls. 147. O Acusado foi notificado pessoalmente, fls. 155, a Defesa apresentou defesa preliminar, cumulada com pedido de liberdade provisória, fls. 159/162, o Órgão Acusador manifestou-se, fls. 166/167. A denúncia foi recebida, e, na oportunidade, foi acolhido o pedido da defesa, fls. 168/169. Diante da alteração de endereço por parte do Réu, o Promotor de Justiça requereu novamente a decretação da prisão preventiva, fls. 193, o pedido foi acolhido, fls. 194/195. O Réu foi citado por edital, fls. 208, o mandado de prisão, cumprido, fls. 230/232, e

após o Acusado foi citado pessoalmente, fls. 240. Durante a audiência de instrução, debates e julgamento, foi ouvida uma testemunha presente e realizou-se o interrogatório (gravação por videoconferência). Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação, e a Defesa, a absolvição. É o relatório. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade do delito de tráfico acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 07/09, no Auto de Exibição e Apreensão, fls. 10/11, no Laudo de Constatação, fls. 17/19, bem como no Exame químico-toxicológico n. 211559/2020, fls. 61/64, contatando-se a presença do princípio ativo COCAÍNA. William de Medeiros Santos, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando receberam denúncias de uma pessoa, a qual apontou o Réu como sendo o responsável pela venda de entorpecentes e inclusive se deslocava ao matagal para fazer a entrega das drogas aos compradores; foram ao local indicado e encontraram o Acusado, com o qual houve apreensão de cinco porções de "crack" e de dinheiro; os policiais fizeram buscas no matagal e encontraram outras porções de "crack" e de "cocaína". Reinaldo Santos Alapone, Réu, ao ser interrogado, disse que estava indo levar dinheiro para a ex-esposa, e, no caminho, passou por esse local, onde havia duas pessoas, que, ao verem a viatura, assustaram-se e fugiram, deixando para trás os entorpecentes; os policiais "colocaram" os entorpecentes no Réu e o conduziram. Confrontando-se a prova coligida, verifica-se que a parcial procedência é medida que se impõe, pois os policiais abordaram o Acusado e com ele encontraram cinco porções de "crack", portanto pequena quantidade e compatível com a destinação própria, havia poucas unidades e não foi presenciado qualquer ato de fornecimento. Tratando-se de usuário de entorpecentes, óbvio que as drogas lhe pertenciam, notadamente porque estavam consigo, todavia, ausentes informações de venda, a conclusão é que as drogas eram destinadas ao uso pelo Acusado. Em relação às outras porções encontradas no moto, não podem ser imputadas ao Acusado, pois nem mesmo os policiais o viram dispensar essa droga ou até mesmo reiteradamente se deslocar ao terreno para atender usuários. Por fim, apesar da apreensão de dinheiro e da denúncia anônima, à míngua de outros elementos, tais provas são insuficientes para a condenação por tráfico de entorpecentes. A tese do Réu, segundo a qual as drogas, que os policiais disseram ter encontrado com ele, eram de duas pessoas que se evadiram ao ver os policiais, restou isolada e inverossímil e não merece ser acolhida. Em síntese, em virtude de todas essas circunstâncias, não se autoriza a prolação de decreto condenatório por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas e mister é a desclassificação da conduta imputada ao Réu para a tipificada no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, o que faço com fulcro no artigo 383 do Código de Processo Penal. II – DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. ART. 28, DA LEI 11.343/2006: Atento às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e aos critérios contidos no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 aplico ao Réu a pena de advertência. III – DECIDO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e o faço para DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia e o faço para condenar, REINALDO SANTOS ALAPONE, qualificado nos autos, a pena de ADVERTÊNCIA, dando-o como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06. Dá-se a pena por cumprida. Defiro a liberação do dinheiro. Sem condenação nas custas. O Réu estava preso em virtude do descumprimento de medida cautelar e, neste momento, considerando-se o encerramento da instrução criminal e à vista da pena aplicada, poderá interpor eventual recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura, com urgência. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 17 de março de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA